

1006367-27.2022.8.26.0010

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes

Magistrado: LIGIA MARIA TEGAO NAVE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional X - Ipiranga

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... bancárias que a autora sustenta não ter realizado. Furto de valor noticiado à autoridade policial. Impugnação administrativa rejeitada. Banco réu que alega excludente de sua responsabilidade, pela utilização de biometria e senha pessoal, cujo dever de guarda seria da correntista. Ausência de documentos comprobatórios acerca da regularidade das operações. Inteligência do artigo 6º, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional X - Ipiranga

2ª Vara Cível

Rua Agostinho Gomes, 1455, São Paulo - SP - cep 04206-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1006367-27.2022.8.26.0010 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1006367-27.2022.8.26.0010

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes

Requerente:

Clovis Pereira de Carvalho

Requerido:

Banco Bradesco S.A.

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LIGIA MARIA TEGAO NAVE

Vistos.

CLÓVIS PEREIRA DE CARVALHO ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. indenização por danos materiais e morais, e pedido de tutela de urgência, contra BANCO BRADESCO S.A. alegando, em síntese, que, ao identificar várias despesas desconhecidas em sua fatura de cartão de crédito, entrou em contato com o réu solicitando informações, no entanto, não obteve resposta (número de protocolo 211200112426737). Acrescenta que dirigiu-se a uma agência e foi atendido pelo gerente que o informou que seu cartão de crédito havia sido clonado, e que, portanto, realizaria o bloqueio do cartão, bem como o quebrou na sua frente, jogando-o no lixo. Sustenta, no entanto, que apesar do registro formal de impugnação, lhe foi dito que, por ter realizado o pagamento da fatura do mês de novembro de 2021, o mesmo teria anuído com as compras realizadas de maneira fraudulenta em seu cartão de crédito, e que, desse modo, teria que pagar as faturas. Não obstante, nos meses subsequentes continuaram a chegar valores exorbitantes em suas faturas, com compras que jamais foram realizadas pelo autor. Diz que tentou novamente contato na agência bancária para solucionar a questão, em

vão, bem como passou a receber cobranças por telefone. Menciona ter realizado boletim de ocorrência sobre os fatos e alega ter sido surpreendido com a informação de que seu nome foi inserido em cadastro de proteção ao crédito. Invoca o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 297 do C.STJ. Requer a declaração da inexigibilidade do débito e a restituição de R\$ 1.648,43, além de danos morais que estima também em R\$ 24.240,00 (fls. 01/30). Juntou documentos (fls. 31/56).

A tutela de urgência foi indeferida, e foi determinado ao autor a emenda da inicial para indicar quais transações foram lançadas no cartão de crédito, que não foram por ele realizadas (fls. 68).

Contestação às fls. 72/92 impugnando a concessão da gratuidade da justiça ao autor. No mérito, alega que as operações questionadas foram autorizadas por meio de senha, o que afasta a responsabilidade do banco, por indicar descuido do detentor. Diz não ter praticado qualquer ato ilícito e que a situação vivenciada pelo demandante não configura violação dos direitos de personalidade capaz de gerar danos morais indenizáveis. Sustenta a ausência de falha na prestação de serviços e a inexistência de valores a serem ressarcidos. Aponta para a impossibilidade de inversão do ônus da prova pretendida. Trouxe documentos (fls. 93/156).

Petição do autor trazendo a relação de operações que desconhece, e comprovação da inserção (fls. 160/163), dos quais foi o réu intimado (fls. 166), tendo se manifestado às fls. 167/168.

Réplica às fls. 169/188.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Passo ao julgamento antecipado da lide porque desnecessária a dilação probatória (art. 355, I, do CPC). Oportuno lembrar que, ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, cumpre determinar aquelas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir aquelas inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370 do CPC), de modo a assegurar a razoável duração do feito (artigo 139 do CPC).

I - Rejeito a impugnação à gratuidade processual concedida ao autor.

O art. 99, §3º do CPC pressupõe verdadeira a afirmação de pessoa natural de ausência de condições de pagar as custas, as despesas do processo e os honorários advocatícios. Já o §2º do mesmo artigo ressalva: "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".

Não há nos autos quaisquer circunstâncias que apontem incompatibilidade entre a situação financeira do autor e o pretendido benefício, não tendo a parte contrária produzido provas de que aquele possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e/ou da família, ônus que lhe competia.

II - No mérito, a ação é parcialmente procedente.

Incontroverso (artigo 374 do Código de Processo Civil) possuir o requerente o cartão de crédito do réu. E, nessa qualidade, alega ter sido surpreendido com seu nome inserido em cadastro de proteção ao crédito pelo réu, por dívida que não reconhece. Levado ao conhecimento do réu o fato de não reconhecer as compras efetuadas, e lavrado Boletim de Ocorrência, o réu recusou-se a cancelar o valor das operações.

Em contestação, por sua vez, o requerido defende não ter qualquer responsabilidade sobre as operações, sob o argumento de que as transações foram realizadas mediante uso da senha pessoal do autor, inexistindo falha na prestação dos serviços bancários.

O Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável ao caso, uma vez que a requerida é fornecedora de produtos (artigos 2º e 3º daquele diploma legal). Oportuno, nesse sentido, que se recorde a Súmula nº297, do Colendo STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Prevê o art. 14 do CDC: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". E acrescenta o § 3º do mesmo

dispositivo legal que: "O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".

Já o artigo 6º, VIII, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova para facilitação da defesa dos direitos do consumidor sempre que: "a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;".

Na hipótese, competia ao banco demonstrar a regularidade das operações bancárias (artigo 373, II, do CPC). Entretanto, o réu não se desincumbiu do ônus que lhe assistia. Destaque-se, nesse sentido, que não há como se exigir do demandante a produção de prova negativa, de que não conferiu seu cartão e senha ao terceiro fraudador.

Ademais, incontroverso que as compras, realizadas em sequência, foram feitas em estabelecimentos diversos, o que aponta para a fraude. De mais a mais, o expressivo valor delas, em completa discrepância do padrão até ali mantido pelo demandante (fls. 48/56), é fato, por si só, suficiente para acionar o sistema de segurança do banco o que, não ocorrendo, constitui falha na prestação de serviços. Deve-se, nesse particular, dizer, que o estabelecimento bancário tem o dever de prestar serviço seguro ao cliente. A vulnerabilidade do sistema é risco da própria atividade que exerce e da qual auferir lucro, não podendo o prejuízo ser repassado ao consumidor. Desta forma, havendo fraude praticada por terceiro, o banco deve ser responsabilizado pela reparação dos danos sofridos por seus clientes, pois configurada a falha na prestação dos seus serviços.

Não há qualquer elemento indicativo de que as operações contestadas foram realizadas pelo requerente ou de ter ele contribuído, de qualquer modo, para a ocorrência da fraude. Assim sendo, não pode ser compelido a responder por débitos contraídos por terceiros fraudadores.

Neste sentido:

"RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória cumulada com indenizatória. Retirada de valores de conta corrente. Transferências não reconhecidas pela correntista. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco requerido a restituir à autora os descontos relativos às movimentações bancárias, no valor de R\$ 97.800,00, além de condená-lo ao pagamento de R\$ 5.000,00, a título de indenização pelos danos morais sofridos. Insurgência de ambas as partes. Inadmissibilidade. Relação negocial regida pelo CDC. Transferências bancárias que a autora sustenta não ter realizado. Furto de valor noticiado à autoridade policial. Impugnação administrativa rejeitada. Banco réu que alega excludente de sua responsabilidade, pela utilização de biometria e senha pessoal, cujo dever de guarda seria da correntista. Ausência de documentos comprobatórios acerca da regularidade das operações. Inteligência do artigo 6º, inciso VIII, da legislação protetiva. Falha na prestação do serviço caracterizada. Responsabilidade pelo risco da atividade. Fraude realizada por terceiro que não exime o banco de responsabilidade. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ. Danos materiais que devem ser ressarcidos. Dano moral configurado. Valor bem fixado pelo D. Juízo de Origem, proporcional e razoável aos elementos do caso concreto. Manutenção da verba honorária expressamente consignada na sentença em R\$ 2.000,00 (dois mil reais), adequadamente fixada com base no princípio da equidade, nos termos do artigo 85, § 8º do novo Código de Processo Civil. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recursos não providos". Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos rejeitados." (Embargos de Declaração nº1018337-90.2020.8.26.0625, 18ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Helio Faria, j. 29.10.2021).

"RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização Prestação de serviços bancários Transferência indevida de numerário em conta corrente, por meio do sistema denominado "internet banking" Falha imputável ao Banco-réu, que responde objetivamente pelos prejuízos da autora Ato ilícito e falha na prestação do serviço bancário Restituição à autora dos valores indevidamente transferidos

Admissibilidade Dano moral Ocorrência Desnecessidade de prova Dano "in re ipsa" Indenização fixada em R\$ 10.000,00 Valor mantido Inovação da tese defensiva no apelo Matéria que não pode ser conhecida - Sentença mantida Honorários recursais Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor total da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso conhecido em parte e desprovido na parte conhecida, com observação." (Apelação nº1014146-29.2017.8.26.0068, 20ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. 20.01.2020).

De rigor, portanto, sejam canceladas as operações relacionados às fls. 160, no cartão de crédito do autor, fornecido pelo requerido. O valor que já foi pago deverá ser restituído ao autor, acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP a partir do pagamento da fatura, com juros de mora a partir da citação. De outro lado, e conforme entendimento jurisprudencial acima colacionado, situações assemelhadas àquela noticiada nos autos ensejam indenização por danos morais, pois evidente o constrangimento de quem, subitamente, descobre compras fraudulentas em seu cartão de crédito, configurando evidente falha na prestação de serviços pelo banco, que se nega a ressarcir o prejuízo.

E constitui entendimento consolidado na atualidade a afirmação de que a condenação em danos morais, embora deva atender ao seu duplo fim, deve ressarcir os prejuízos sofridos, mas não pode servir de motivo para enriquecimento sem causa.

A condenação em dano moral não pode ser tal que a pessoa deseje sofrê-lo novamente. Por outro lado, não pode ser ínfimo, devendo desestimular nova conduta por parte de quem cometeu o ilícito.

Uma vez que nenhuma possibilidade há de medir pelo dinheiro um sofrimento puramente moral, Caio Mário da Silva Pereira recomenda que faça um jogo duplo de noções: "a) de um lado, a idéia de punição do infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia; b) de outro lado, proporcionar à vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é o pretium doloris" (Instituições de Direito Civil, 8ª ed., Rio, Forense, 1986, vol. II, nº 176, pág. 235).

A jurisprudência, também, fixa as bases do dano moral:

"Com efeito, 'O dano moral, se não é verdadeiramente, dano suscetível de fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente' (Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, T. 54, 5.536, no. 1, p.61). 'O importante é a par do princípio da reparabilidade, admitir o da indenizabilidade, para que, como assinalam os autores, não fique a lesão moral sem recomposição, nem impune aquele que por ela é responsável, fatores, ambos, que seriam de perpetuação de desequilíbrios sócio-jurídicos.'" (R. Limongi França, Reparação do Dano Moral, in RT 631/135).

"A indenização por dano moral é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa" (RJTJESP 156/94 e RT 706/67).

Assim, levando em conta as particularidades do caso concreto, fixo o valor dos danos morais em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente para que a instituição financeira requerida procure melhorar seus serviços e para proporcionar ao requerente a reparação coerente com os danos sofridos. A correção monetária dar-se-á a partir do arbitramento (Súmula 362, do STJ), com juros de mora a partir da citação.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente ação para:

(i) DECLARAR a inexigibilidade do débito relativo às operações descritas às fls. 160, no cartão de crédito fornecido pelo banco ao requerente;

(ii) DETERMINAR ao requerido a devolução, em prol do autor, dos valores que já foram pagos, relativos às essas operações, nos termos da fundamentação. Os valores serão acrescidos de correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP a partir do pagamento da fatura e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

(iii) CONDENAR o banco requerido ao pagamento da quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pelo requerente, acrescida de correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros

de mora de 1% ao mês a partir da citação;
(iv) DETERMINAR o cancelamento do apontamento descrito às fls. 163. Providencie-se via Serajud.

Em razão do disposto na Súmula n. 326 do STJ, arcará o réu com o pagamento das custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

P. R. I. C.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA